

1523088-42.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... que o levaram por suspeita de roubo, não tinha vítima no local. Eles tiraram umas fotos e o liberaram, ficando com o seu telefone. Depois contratou um advogado para retirar seu telefone. O delegado disse que no local tinham varios roubos. Não pegaram celulares com o depoente, só o dele.

A negativa do réu não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos.

A vítima NATALIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523088-42.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523088-42.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2218691/2020 - 23º D.P. PERDIZES, 8925373 - 23º D.P. PERDIZES, 3050/20/342 - 23º

D.P. PERDIZES, 2218691 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO CARLOS RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

CRISTIANO CARLOS RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea 'j', ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de junho de 2020, por volta das 09h30, na Avenida Antártica, n.º 1, Barra Funda, nesta cidade e comarca, durante o período da pandemia, mediante rompimento de obstáculo, consistente no vidro do veículo do lado do passageiro, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefonia celular da marca Apple, modelo Iphone 8, cor cinza, não apreendido, de propriedade da vítima Natália Maria dos Reis. Diante das condições da pandemia, o denunciado praticou o crime em estado de calamidade pública gerada pelo COVID-19.

Segundo a exordial, na data dos fatos, a vítima estava conduzindo seu veículo pelo local dos fatos, quando parou no semáforo. Neste instante, o denunciado, de posse de um objeto, inopinadamente, quebrou o vidro do veículo do lado do passageiro, debruçou-se no interior do veículo, apanhou o aparelho de celular da vítima e saiu em fuga, não sendo mais localizado. No Distrito Policial, forneceu as

características do indivíduo e, em observação às fotografias, reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado CRISTIANO como sendo o autor do delito (fls. 09/10).

Na denúncia foram arroladas a testemunha MARCUS VINICIUS HENESS e vítima: NATALIA MARIA DOS REIS.

Recebida a denúncia em 03/11/2021 às fls. 82/83.

O réu foi citado (fls. 97).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 102. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 105/106), foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 160/161).

O réu foi devidamente intimado para a audiência (fls. 156).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 130/134, sendo o réu reincidente com maus antecedentes.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Furto Qualificado pelo rompimento de obstáculo.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel."

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), termo de declarações e interrogatório (fls. 8), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 9) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

O mesmo não é possível dizer da autoria.

Na delegacia, o réu CRISTIANO CARLOS RIBEIRO não foi interrogado.

Em juízo, o réu CRISTIANO CARLOS RIBEIRO disse que estava no ponto de ônibus quando foi enquadrado pelos policiais que o levaram por suspeita de roubo, não tinha vítima no local. Eles tiraram umas fotos e o liberaram, ficando com o seu telefone. Depois contratou um advogado para retirar seu telefone. O delegado disse que no local tinham vários roubos. Não pegaram celulares com o depoente, só o dele.

A negativa do réu não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos.

A vítima NATALIA MARIA DOS REIS disse que estava parada no semáforo quando um meliante veio, passou na frente do carro, olhou e foi no meio fio e ficou o acompanhando no retrovisor, ele saiu da sua visão e então ele estourou o vidro e furtou seu celular. Ele correu mas não viu para onde. Parou numa área e uma pessoa a ajudou. Prestou BO e cerca de 1 mês um policial civil disse que fez a apreensão de uma pessoa que era compatível com a sua descrição e depois conseguiram recuperar seu celular que estava sendo enviado para um país africano. Fez o reconhecimento

por foto por whatsapp, porque estava no auge da pandemia, então lhe mandaram 5 FOTOS DA MESMA PESSOA em várias direções e não teve dúvida na época. Passou as características físicas, ele era moreno claro, estava arrumado, de camiseta polo, cabelo com gel baixinho, o cabelo era preto. Ele não passou na faixa de pedestres, ele passou entre os carros. Não tinham outras pessoas, ele esperou um tempo para atravessar. A foto era colorida. O celular estava no painel, o vidro estourado era o do passageiro. Não viu quem estourou o vidro, associou com a pessoa que passou na frente do carro porque ele não atravessou na faixa. O policial disse que o furto sofrido pela depoente depois que ela reconheceu era parecido com os furtos pelo qual o réu foi preso. Em reconhecimento a vítima disse que o réu se parece com a pessoa do dia dos fatos.

Ainda que a vítima tenha reconhecido o réu, é de se ressaltar que tal reconhecimento seu deu FOTOGRAFICAMENTE sem respeito ao artigo 226 do CPP, momento em que lhe foi apresentada apenas fotos do réu e não com fotos de terceiros, certamente maculando a prova, dado que mais de mês após ao fato foi lhe enviada foto de uma pessoa acusada de crime similar.

Não bastasse isso, a ofendida afirmou que não foi possível ver quem de fato teria subtraído seu celular, sendo que a conduta imputada ao réu por ela foi ter passado fora da faixa olhando para seu veículo. Ainda que possa se considerar tal conduta suspeita, sem dúvida não é suficiente para gerar um decreto condenatório, até porque plenamente comum que pessoas atravessem fora da faixa, tendo ela dito que perdeu o réu de vista, não sendo possível ver se ela foi em direção a seu veículo. Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

No caso em tela ficou claro que não foi respeitado o procedimento do artigo 226 do CPP já que a vítima foi exposta apenas a fotos do réu em varias direções indicadas pela autoridade policial como suspeito de crimes similares, o que sem dúvida gera uma predisposição para o reconhecimento.

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a

memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização.

(MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

O policial ouvido em juízo também não soube esclarecer se o réu foi detido pelo cometimento de crime similar ou para averiguação, não sendo nem mesmo possível saber como se deu a investigação.

A testemunha MARCUS VINICIUS HENESS afirmou que receberam grande demanda de furto com o mesmo modus operandi. Indivíduos vinham no semáforo, quebravam os vidros e levavam os celulares. Fizeram a investigação e pessoas detidas próximas ao local e quando estavam com objeto para quebrar vidro eram levadas para a delegacia para reconhecimento. O réu foi detido com uma caneta com uma ponta de metal usada para estourar vidro. Pegaram a fotografia do réu e enviavam por mensagem para as vítimas. Separavam fotos de várias pessoas com características parecidas presas em atitude suspeita, entre 5 ou 6 fotos e as vítimas apontavam quem era o furtador. O réu confessou o delito e apontou para onde os celulares eram levados, tanto que tal local ainda é objeto de operações policiais. Eles tinham bastante lucro, pois eles vendiam para os Nigerianos quase que pelo valor de mercado do bem. Não se lembra se o réu foi detido em flagrante ou em uma abordagem. A vítima se chamava Natália, e acredita que o reconhecimento foi por whatsapp e depois ela foi na delegacia. As fotos eram mandadas conforme iam sendo feitas as apreensões, uma foto por vez. A Natalia disse que era homem, jovem, branco, cabelo preto, entre 15 e 25 anos.

Assim, o que se tem no feito é um (i) reconhecimento fotográfico; (ii) feito apenas com fotos do réu sem fotos de outras pessoas similares, (iii) não confirmado em juízo, já que a vítima não teve certeza quando lhe mostrada 3 pessoas, (iv) sem que a ofendida tenha identificado o acusado como a pessoa que subtraiu seu celular, mas apenas aquele que passou na frente de seu veículo olhando e depois não viu mais, (v) não há indicação de fato de como se deram as investigações, conforme relato do policial e (vi) com o réu nada de ilícito foi encontrado, sendo a absolvição medida que se impõe.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso. Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu CRISTIANO CARLOS RIBEIRO, qualificado nos autos, das sanções artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA